CY Cergy Paris Université

Faculté de Droit

Année universitaire 2026-2027

TRAVAUX DIRIGES – **2ème année Licence Droit**
DROIT DES OBLIGATIONS
Cours de madame la professeure Magali Jaouen

SIXIÈME SÉANCE

Semaine du 09 novembre 2026

LA NOTION DE CONTENU DU CONTRAT (1)
L'EXIGENCE D'UN CONTENU LICITE ET CERTAIN

Documents

I.- Un contenu licite : un but et des stipulations contractuelles conformes à l'ordre public

Document n° 1 : **Cass. 1re, 12 juillet 1989**, n° 88-11.443, Bull. civ. I, n° 293

Document n° 2 : **Cass. 1re, 7 octobre 1998**, n° 96-14.359, Bull. civ. I, n° 285

Document n° 3 : **Cass. A.P., 29 octobre 2004**, n° 03-11.238, Bull. civ. A.P., n° 12

Document n° 4 : **Cass. 1re civ. 29 octobre 2014**, n° 13-19.729, Bull. civ. I, n° 178 (Extraits)

Document n° 5 : **Cass. 3ème civ., 22 mars 2006,** n° 04-19.349, Bull. civ. III, n° 73, obs. J.-B. Seube, *RDC* 2006, n° 4, p. 1149 (reproduite sous l'arrêt).

Document n° 6 : **Cass. com., 27 mai 2021**, n° 18-23.261, n° 18-23.699 (Extraits)

II.- Un contenu certain : la protection des intérêts individuels

Document n° 7 : **Cass. 1re civ. 16 avril 1996**, n° 93-19.661, Bull. civ. I, n° 184

Document n° 8 : **Cass. 1re civ., 3 juillet 1996**, n° 94-14.800, Bull. civ. I, n° 286

Document n° 9 : **Cass. com., 9 juin 2009**, n° 08-11.420, *inédit*

Exercices

1° Lisez l'ensemble des arrêts communiqués **et** réalisez, **pour chacun**, **une fiche d'arrêt**.

2° Commentaire d'arrêt : Cass. com. 9 juin 2009, n° 08-11.420, inédit (**doc n° 9**)

Vous **rédigerez au propre sur votre copie** le commentaire de cet arrêt.

LECTURES RECOMMANDÉES

Pour vous permettre d'approfondir vraiment la thématique au cœur de l'arrêt soumis à votre analyse, il est vivement recommandé d'aller chercher et de lire les références suivantes :

- G. WICKER, « La suppression de la cause par le projet d'ordonnance : la chose sans le mot ? », *D.* 2015, n° 27, p. 1767 (N.B. ATTENTION ! cet article s'appuie sur *le projet d'ordonnance* élaboré en 2015 et non sur le texte définitif de l'ordonnance du 10 février 2016)

- F. TERRÉ, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, F. CHÉNEDÉ, *Les grands arrêts de la jurisprudence civile* (GAJC), Tome 2, 14e éd., Dalloz, 2024** : lire le commentaire de chacun de ces 2 arrêts :
  - Cass. 1ère civ., 12 juillet 1989 (PIRMAMOD v. doc. n° 4) comm. n° 183, p. 131 et s.
  - Cass. 1ère civ., 7 octobre 1998 (v. doc. n° 5) comm. 185, p. 169 et s.

** ouvrage consultable sur la base de données DALLOZ : onglet « Documentation --> Ouvrages --> bibliothèque Lefèbvre Dalloz

I.- Un but et des stipulations contractuelles conformes à l'ordre public

Document n° 1 : **Cass. 1re civ., 12 juillet 1989**, n° 88-11.443, Bull. civ. I, n° 293

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'en 1981, M. Y..., parapsychologue, a vendu à Mme X..., elle-même parapsychologue, divers ouvrages et matériels d'occultisme pour la somme de 52 875 francs ; que la facture du 29 décembre 1982 n'ayant pas été réglée, le vendeur a obtenu une ordonnance d'injonction de payer, à l'encontre de laquelle Mme X... a formé contredit ; que l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1987) a débouté M. Y... de sa demande en paiement, au motif que le contrat de vente avait une cause illicite ;

Attendu que M. Y... fait grief audit arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cause du contrat ne réside pas dans l'utilisation que compte faire l'acquéreur de la chose vendue, mais dans le transfert de propriété de cette chose, et qu'en prenant en compte, pour déterminer cette cause, le prétendu mobile de l'acquéreur, la cour d'appel aurait violé les articles 1131, 1133 et 1589 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en déclarant nulle pour cause illicite la vente d'objets banals au prétexte que ceux-ci pourraient servir à escroquer des tiers, bien qu'il soit nécessaire que le mobile illicite déterminant soit commun aux deux parties sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'utilisation personnelle que l'acquéreur entend faire à l'égard des tiers de la chose vendue, l'arrêt attaqué aurait de nouveau violé les textes susvisés ;

Mais attendu, d'abord, que si la cause de l'obligation de l'acheteur réside bien dans le transfert de propriété et dans la livraison de la chose vendue, en revanche la cause du contrat de vente consiste dans le mobile déterminant, c'est-à-dire celui en l'absence duquel l'acquéreur ne se serait pas engagé ; qu'ayant relevé qu'en l'espèce, la cause impulsive et déterminante de ce contrat était de permettre l'exercice du métier de deviner et de pronostiquer, activité constituant la contravention prévue et punie par l'article R. 34 du Code pénal, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une telle cause, puisant sa source dans une infraction pénale, revêtait un caractère illicite ;

Attendu, ensuite, que M. Y... exerçait la même profession de parapsychologue que Mme X..., qu'il considérait comme sa disciple ; qu'il ne pouvait donc ignorer que la vente de matériel d'occultisme à celle-ci était destinée à lui permettre d'exercer le métier de devin ; que la cour d'appel n'avait donc pas à rechercher si M. Y... connaissait le mobile déterminant de l'engagement de Mme X..., une telle connaissance découlant des faits de la cause ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi

Document n° 2 : **Cass. 1re civ., 7 octobre 1998**, n° 96-14.359, Bull. civ. I, n° 285

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, par acte sous seing privé du 17 juin 1981, M. X... a reconnu devoir à son épouse une somme, remboursable avec un préavis de trois mois ; qu'après leur divorce, Mme X..., devenue Mme Y..., a, par acte du 14 juin 1989, accepté que le prêt lui soit remboursé sous forme d'une augmentation de la pension alimentaire que lui versait son ex-mari ; qu'en 1993, elle l'a assigné en remboursement du solde du prêt ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 1996) d'avoir annulé pour cause illicite l'acte du 14 juin 1989 et fait droit à la demande de son ex-épouse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne constatant pas que l'accord avait eu pour motif déterminant des déductions fiscales illégales et en ne recherchant pas s'il n'avait pas eu pour motif déterminant de réaliser l'étalement du remboursement du prêt dont le paiement était susceptible d'être réclamé à tout moment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'une convention ne peut être annulée pour cause illicite que lorsque les parties se sont engagées en considération commune d'un motif pour elles déterminant ; qu'ayant constaté que Mme Y... déclarait à l'administration fiscale l'intégralité des sommes reçues de M. X..., il s'en évinçait que Mme Y... ne pouvait avoir eu pour motif déterminant de son accord la déductibilité, par M. X..., des sommes à elles versées, en sorte que la cour d'appel, en retenant une cause illicite, a violé l'article précité ;

Mais attendu qu'un contrat peut être annulé pour cause illicite ou immorale, même lorsque l'une des parties n'a pas eu connaissance du caractère illicite ou immoral du motif déterminant de la conclusion du contrat ; que l'arrêt ayant retenu que l'acte du 14 juin 1989 avait une cause illicite en ce qu'il avait pour but de permettre à M. X... de déduire des sommes non fiscalement déductibles, Mme Y... était fondée à demander l'annulation de la convention ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante visée à la première branche du moyen, a légalement justifié sa décision

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi

Document n° 3 : **Cass. A.P., 29 octobre 2004**, n° 03-11.238, Bull. civ. A.P., n° 12

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 900, 1131 et 1133 du Code civil ;

Attendu que n'est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes moeurs la libéralité consentie à l'occasion d'une relation adultère ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Première Chambre civile, 25 janvier 2000, pourvoi n° D 97-19.458), que Jean X... est décédé le 15 janvier 1991 après avoir institué Mme Y... légataire universelle par testament authentique du 4 octobre 1990 ; que Mme Y... ayant introduit une action en délivrance du legs, la veuve du testateur et sa fille, Mme Micheline X..., ont sollicité reconventionnellement l'annulation de ce legs ;

Attendu que, pour prononcer la nullité du legs universel, l'arrêt retient que celui-ci, qui n'avait "vocation" qu'à rémunérer les faveurs de Mme Y..., est ainsi contraire aux bonnes moeurs ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; (…)

Document n° 4 : **Cass. 1re civ. 29 octobre 2014**, n° 13-19.729, Bull. civ. I, n° 178 (Extraits)

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'interdiction qui lui a été faite de poursuivre l'exposition de cadavres humains « Our Body / A corps ouvert » organisée à Paris à partir du 12 février 2009, la société Encore Events a assigné les sociétés Groupe Pont Neuf, Areas, Cameic et Liberty Syndicate, ses assureurs, en garantie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Encore Events fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat d'assurance conclu le 7 novembre 2008 pour illicéité de sa cause, alors, selon le moyen :

1°/ que les conditions de validité d'une convention s'apprécient au regard du droit applicable le jour de sa formation ; qu'en estimant néanmoins que le contrat d'assurance conclu le 7 novembre 2008 a une cause illicite quand l'illicéité de l'exposition « Our Body / A corps ouvert » et donc celle du contrat d'assurance ne résultent, au regard de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 septembre 2010 (pourvoi n° 09-67.456), que de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 qui a créé l'article 16-1-1 du code civil et qui est postérieure à la date de formation du contrat d'assurance litigieux, la cour d'appel a violé les articles 2 et 1131 du code civil ;

2°/ que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; qu'en estimant néanmoins que la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008, qui ne comportait aucune disposition transitoire relativement à l'entrée en vigueur du nouvel article 16-1-1 du code civil, pouvait être considérée comme rétroactive, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ;

Mais attendu que le principe d'ordre public, selon lequel le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort, préexistait à la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 d'où est issu l'article 16-1-1 du code civil ; qu'ayant relevé que le contrat d'assurance souscrit le 7 novembre 2008 par la société Encore Events avait pour objet de garantir les conséquences de l'annulation d'une exposition utilisant des dépouilles et organes de personnes humaines à des fins commerciales, la cour d'appel en a exactement déduit que, bien qu'ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de l'article 16-1- 1 précité, le contrat litigieux avait une cause illicite et, partant, qu'il était nul ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; (…)

Document n° 5 : **Cass. 3ème civ., 22 mars 2006,** n° 04-19.349, Bull. civ. III, n° 73

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 8-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 janvier 2004), que la Société Martiniquaise d'habitations à loyer modéré (SMHLM) a donné en location un appartement à Mme Marie-Josée X... et à M. Y..., le 28 novembre 1980 ; qu'après avoir quitté les lieux, M. Y... a fait assigner Mme Pierrette X..., la fille de sa colocataire, pour obtenir son expulsion et que Mme Marie-Josée X... est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que pour accueillir cette demande et condamner Mmes Pierrette et Marie-Josée X... au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que Mme Marie-Josée X... est à ce jour cotitulaire du bail, que, sauf enfant mineur, un des cotitulaires ne peut imposer à l'autre la présence d'une tierce personne majeure alors que le bail stipule une clause d'habitation personnelle prohibant toute sous-location, cession et mise à disposition gratuite de l'appartement, et que Mme Marie-Josée X... maintient dans les lieux sa fille majeure dans une situation illicite au regard du bail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme Pierrette X... avait établi sa résidence chez sa mère qui occupait personnellement le logement et que les clauses d'un bail d'habitation ne peuvent avoir pour effet de priver le preneur de la possibilité d'héberger ses proches, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

***

Note J.-B. Seube, « Le contrat de bail, les droits fondamentaux et l'ordre public », *RDC* 2006, n° 4, p. 1149

Contracter sur les droits fondamentaux ? - Présidée par le premier président de la Cour de la cassation, la troisième Chambre civile a réitéré une importante solution dégagée dix ans auparavant : les clauses d'un bail ne peuvent, au regard de l'article 8-1 de la Convention européenne des droits de l'homme (Convention EDH), avoir pour effet de priver un locataire du droit d'héberger ses proches (Cass. civ. 3e, 6 mars 1996, Bull. civ. III, no 60, RTD civ. 1996, p. 897, obs. J. Mestre et p. 1024, obs. J.-P. Marguénaud, JCP G 1996, I, 3958, no 1, obs. Ch. Jamin, D. 1996, som. p. 379, obs. CRDP Nancy II, D. 1997, p. 167, obs. B. de Lamy, RDI 1996, p. 620, obs. Fr. Collart Dutilleul, AJPI 1996, p. 7, obs. B. Wertenschlag).

La réitération décennale de la solution qui marquait le début du mouvement de « fondamentalisation » du contrat intervient dans un contexte particulier. Depuis 1996, en effet, de nombreuses décisions ont montré l'influence croissante des droits fondamentaux dans le contrat, qu'ils permettent la neutralisation des clauses contractuelles ou la vivification de l'accord par la greffe de dispositions nouvelles (par ex., Cass. civ. 3e, 18 déc. 2002 et 12 juin 2003, RDC 2004, p. 231, obs. J. Rochfeld et p. 348, obs. G. Lardeux et les réf.). Depuis 1996 également, d'importants travaux doctrinaux ont été consacrés à la question (A. Debet, L'influence de la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit civil, préface L. Leveneur, Dalloz, 2002 ; J. Raynaud, Les atteintes aux droits fondamentaux dans les actes juridiques, préface E. Garaud, PUAM, 2003) et les voix soulignant les écueils de ce que Philippe Rémy a appelé la « droit de l'hommisation » du droit privé (Ph. Rémy, « Ouverture », in Les concepts contractuels français à l'heure des Principes du droit européen des contrats, sous la direction P. Rémy-Corlay et D. Fenouillet, Dalloz, 2003, p. 7) sont de plus en plus nombreuses (par ex., M.-E. Ancel, « Nouvelles frontières : l'avènement de nouveaux ordres juridiques (droit communautaire et droit fondamentaux), in Forces subversives et forces créatrices en droit des obligations, sous la direction de G. Pignarre, Dalloz, 2005, p. 121 ; G. Lardeux et J. Rochfeld, obs. préc. ; J.-B. Seube, RDC 2004, p. 988). C'est donc dans ce contexte particulier, celui de l'émergence des droits fondamentaux dans le contrat et des doutes qui l'accompagnent, qu'il faut discuter la solution de 2006.

On notera, pour commencer, que la Cour réitère ici son attachement à l'effet horizontal de la Convention EDH, c'est-à-dire à son application entre personnes privées et non, comme le voulait la logique de la Convention, entre les personnes privées et l'État signataire. L'originalité de l'arrêt du 22 mars 2006 réside toutefois dans le fait que celui qui poursuivait l'expulsion du proche hébergé par le locataire était l'ancien colocataire ayant quitté les lieux et non, comme c'était le cas en 1996, le propriétaire (sur l'intérêt à agir de l'ancien colocataire, v. Y. Rouquet, obs. préc.). On mesure par là que, insensible aux mises en garde doctrinales relevant que la Convention n'oblige que les États et non les individus (not., G. Lardeux, obs. préc. ; Ch. Jamin, obs. préc. ; M.-E. Ancel, préc.), la Cour de cassation entend dégager une nouvelle virtualité de l'effet horizontal : déjà appliquées entre les contractants (le bailleur et le locataire), les dispositions de la Convention EDH pourront également être invoquées au sein d'une partie plurale (i. e. entre les colocataires). On devine alors que l'ensemble du contentieux contractuel (entre les parties, au sein d'une partie plurale, à l'égard des tiers, etc.) pourrait, à terme, être relu par le prisme des droits fondamentaux. Comme l'écrivait Anne Debet dans sa thèse, aussi intéressant que puisse être le débat sur l'effet horizontal de la Convention EDH, il semble

aujourd'hui dépassé (A. Debet, L'influence de la Convention européenne sur les droits de l'homme, op. cit., nº 59) : qu'on le regrette ou qu'on s'en félicite, la Convention EDH a un effet horizontal et tout se passe comme si l'État, en signant la Convention, avait fait naître un droit dans le patrimoine de ses ressortissants, droit que ces ressortissants pourront ensuite opposer non seulement à l'État signataire, mais aussi aux autres personnes privées.

Cette situation, que notre collègue Marie-Élodie Ancel a qualifié d'« injection des droits de l'homme dans les relations interpersonnelles » (art. préc.), inquiète par l'imprécision des concepts sur lesquels elle repose, par le risque d'arbitraire qui en résulte et par le risque de « dynamitage » des solutions traditionnelles. Judith Rochfeld a, sur ce dernier point, démontré combien le recours aux droits fondamentaux conduisait à l'éviction du raisonnement contractuel classique (RDC 2003, p. 20). Pourtant, l'expérience enseigne que rares sont les révolutions conceptuelles qui ne s'opèrent sans une réaction de la pratique : pour éviter que la digue contractuelle ne rompe sous les assauts des flots tumultueux des droits fondamentaux, il peut alors être tentant pour les contractants de poser le problème plus nettement qu'ils ne le faisaient jusqu'à présent. Quelle valeur, alors, conférer à une clause contractualisant expressément les droits fondamentaux, ainsi rédigée : « en s'interdisant d'héberger des proches autres que ses enfants mineurs, le locataire renonce expressément à se prévaloir contre son contractant de la protection qu'il tient de l'article 8-1 de la Convention EDH » ? Peu explorée par la doctrine civiliste qui appelle à l'érection d'une théorie générale des actes conventionnels sur les libertés (J. Hauser, in RTD civ. 2003, p. 58), la question de la renonciation à un droit fondamental dans sa dimension horizontale annonce de sérieuses difficultés (qui font actuellement l'objet d'une prometteuse recherche, R. Dijoux, La contractualisation des droits fondamentaux, Université de la Réunion). Trois peuvent être rapidement évoquées dans le cadre de cette chronique.

La première difficulté a trait à l'essence des droits fondamentaux reconnus par la Convention EDH. Les adjectifs d'« inaliénable » ou d'« intangible » desquels on les affuble parfois ne militent-ils pas pour que les droits fondamentaux restent hors de portée des volontés individuelles ? La réponse est évidemment négative et l'on a déjà montré que les droits fondamentaux étaient relatifs et que la volonté pouvait valablement les encadrer (J. Raynaud, Les atteintes aux droits fondamentaux dans les actes juridiques privés, op. cit., nos 92 et s. ; plus réservé, J. Hauser, obs. préc.). De fait, en pratique, la Cour EDH admet de longue date que l'on puisse renoncer aux droits processuels ou aux garanties procédurales (par ex., CEDH, 27 févr. 1980, Deweer c/ Belgique, série A, nº 35 ; 8 févr. 2000, Voisine c/ France, RTDH 2001, nº 825, obs. J.-P. Marguénaud ; 10 nov. 2004, Sejdovic c/ Italie, JCP G 2005, I, 103, nº 8, obs. F. Sudre). La question de la renonciation à un droit substantiel est en revanche plus discutée : si l'opinion est fréquemment avancée qu'ils ne peuvent pas faire l'objet d'une renonciation (par ex., J.-P. Marguénaud et B. Dauchez, « Les dispositions transitoires de la loi du 3 décembre 2001 à l'épreuve de la Convention EDH », Defrénois 2002, p. 1366), une étude particulièrement riche révèle cependant que la renonciation aux droits substantiels resterait possible dès lors qu'elle concerne des droits susceptibles de dérogation (Ph. Frumer, La renonciation aux droits et libertés, La Convention européenne des droits de l'homme à l'épreuve de la volonté individuelle, préface R. Ergec, Bruylant, 2001, p. 253 et s. ; v. également, A. Debet, L'influence de la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit civil, op. cit., nos 414 et s. ; J. Raynaud, Les atteintes aux droits fondamentaux dans les actes juridiques privés, op. cit., nos 189 à 192). On ne voit alors guère de raisons pour que la volonté des

individus, prise en compte lorsque l'application de la Convention EDH est verticale, ne le soit plus lorsqu'elle est horizontale : l'identité de la personne devant respecter les droits (l'État ou un autre individu) important peu, il y a tout lieu d'admettre que l'essence des droits fondamentaux ne s'oppose en rien à l'emprise de la volonté.

La deuxième porte sur la coexistence des droits fondamentaux avec l'ordre public interne. Le flou dont se parent les deux notions incite évidemment à la prudence... Une partie importante de la doctrine considère que, parce qu'ils véhiculent des valeurs supérieures sur lesquelles se fonde la société, les droits fondamentaux sont d'ordre public (v. not., B. Fauvarque-Cosson, « L'ordre public », in Le Code civil, un passé, un présent, un avenir, Dalloz, 2004, p. 472). On souligne en effet qu'un intérêt privé peut être d'ordre public « lorsqu'il procède d'une valeur à laquelle la société accorde une importance fondamentale » (G. Cornu, Introduction, Les personnes, Les biens, Montchrestien, 12e éd., 2005, no 341). Toute limitation conventionnelle à un droit fondamental d'ordre public se verrait de fait condamnée, à tout le moins suspectée (par ex., F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, Dalloz, 9e éd., 2005, no 379 ; Ph. Malaurie, L. Aynès et Ph. Stoffel-Munck, Les obligations, Defrénois, 2004, no 652).

Il nous semble pourtant que cette assimilation pure et simple des deux notions s'opère en niant leurs particularités profondes : derrière l'ordre public, il y a la société et l'intérêt général que les volontés individuelles ne peuvent évidemment évincer ; derrière les droits fondamentaux, il y a en revanche l'individu (F. Sudre, Droit européen et international des droits de l'homme, PUF, 7e éd., 2005, no 57) dont la volonté, pourvu qu'elle soit libre et consciente, devrait lui permettre de renoncer au droit qui lui est reconnu. N'est-il donc pas concevable que, quoique proches, ordre public et droits fondamentaux ne se confondent pas toujours (en ce sens, L'ordre public : ordre public ou ordres publics ? Ordre public et droits fondamentaux, sous la direction de M.-J. Redor, Bruylant, coll. « Droit et justice », 2001 ; Ph. Frumer, La renonciation aux droits et libertés, La Convention européenne des droits de l'homme à l'épreuve de la volonté individuelle, op. cit., nos 663 et s. ; J. Raynaud, Les atteintes aux droits fondamentaux dans les actes juridiques privés, op. cit., nos 110 et s.) ? Si l'on prête quelque crédit à l'hypothèse, il pourrait donc exister, entre ordre public et droits fondamentaux, un interstice possible dans lequel la volonté de l'individu, encadrée par le contrat, pourrait efficacement jouer : douteuse et discutable lorsqu'elle contrarie l'ordre public interne (comme la renonciation au droit à la vie par une convention de suicide), la renonciation à un droit fondamental pourrait en revanche développer ses effets dans l'hypothèse inverse.

Même si la proposition ne convainquait pas, il conviendrait, alors, de relever que l'assimilation des droits fondamentaux à l'ordre public n'interdit pas, ipso facto, leur contractualisation, la renonciation aux règles d'ordre public étant admise de longue date (Cass. civ. 3e, 27 oct. 1975, Bull. civ. III, no 310 ; Cass. civ. 1re, 17 mars 1998, JCP G 1998, II, 10148, obs. S. Piedelièvre, Defrénois 1998, p. 749, obs. J.-L. Aubert, Contrats, conc. consom. 1998, comm. no 86, obs. L. Leveneur, RTD civ. 1998, p. 670, obs. J. Mestre). Projection dans le patrimoine de chacun de la règle abstraite posée par l'article 8-1 de la Convention EDH, le droit au respect de la vie familiale pourrait ainsi être l'objet d'une renonciation, même qualifié de texte d'ordre public. On relèvera à cet égard que l'arrêt du 18 décembre 2002 précité a réservé l'hypothèse d'une « convention expresse » intégrant les droits fondamentaux dans le contrat. Par où l'on voit que la validité des clauses ayant pour objet les droits fondamentaux pourrait déjà être admise par la jurisprudence.

La dernière difficulté porte sur l'encadrement de la contractualisation des droits fondamentaux. Eu égard aux développements qui précèdent, on comprend sans peine la suspicion qui pèsera sur la clause contractualisant les droits fondamentaux. La technique contractuelle offre déjà de nombreux modes de contrôle : consentement exprès et non équivoque à la renonciation, justification de l'atteinte, limite de l'abus, etc. Outre ces moyens classiques de contrôle, on sait que, dans l'application verticale de la Convention, les juridictions recourent volontiers au principe de proportionnalité. La même unanimité n'est pas de mise dans son application horizontale : en décidant que « les clauses d'un bail ne peuvent avoir pour effet de priver le preneur de la possibilité d'héberger ses proches », la troisième Chambre civile exclut tout rapport de proportionnalité ; en revanche, la Chambre sociale décide qu'une restriction au libre choix du domicile du salarié « n'est valable qu'à la condition d'être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et proportionnée, compte tenu de l'emploi occupé et du travail demandé, au but recherché » (Cass. soc., 12 janv. 1999, D. 1999, p. 654, note J.-P. Marguénaud et J. Mouly, RTD civ. 1999, p. 395, obs. J. Mestre, et p. 358, obs. J. Hauser ; 12 juill. 2005, RTD civ. 2006, p. 109, obs. J. Mestre et B. Fages).

La jurisprudence de la Chambre sociale s'autorise évidemment de la lettre de l'article L. 120-2 du Code du travail dont l'esprit gagnerait sans doute à investir toutes les relations contractuelles (en ce sens, G. Pignarre, « Vie personnelle du salarié et contrat de travail », LPA, 7 mars 2006, p. 3, n° 22) : on a en effet déjà montré que le refus de prendre en compte la proportionnalité dans une application horizontale de la Convention EDH pouvait conduire à des solutions excessives et grossières, là où le droit contractuel classique aurait permis la nuance et l'équilibre (v., à propos de la conciliation de la vie privée du locataire et du droit, pour le propriétaire, de faire visiter les lieux loués, Cass. civ. 3e, 25 févr. 2004, RDC 2004, p. 988, Defrénois 2004, p. 1721, obs. J.-L. Aubert, Rev. loyers 2004, p. 291, obs. J. Rémy). Encore faut-il que l'éventuel recours à la proportionnalité dans l'application horizontale de la Convention EDH soit bien compris : il ne s'agit évidemment pas de rechercher un équilibre entre la protection de l'individu et celle de l'intérêt général, puisque seuls des intérêts privés sont en jeu (en ce sens, J.-P. Marguénaud et J. Mouly, note préc. ; J. Raynaud, Les atteintes aux droits fondamentaux dans les actes juridiques privés, op. cit., n° 244 ; A. Debet, L'influence de la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit privé, op. cit., n° 251) ; il s'agit simplement de rechercher, comme le fait souvent le juge judiciaire de manière implicite, un point d'équilibre entre deux droits privés qui se télescopent : en l'espèce, peut-être le bailleur - un office HLM - eût-il pu plaider la justification et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit fondamental de son locataire en insistant sur les particularités du logement social (fort intuitu personae du locataire, prise en compte pour l'attribution du logement des personnes à charge, des ressources du foyer, etc.).

En guise de conclusion, on perçoit que l'admission d'un effet horizontal de la Convention EDH rejaillira donc tôt ou tard sur l'influence des volontés sur les droits fondamentaux. Cette volonté ne saurait être niée au prétexte qu'elle porte sur un droit fondamental. « On se méfiera donc de la tendance qui, sous couvert de protéger l'un des contractants contre l'autre, aboutirait à régenter les rapports de l'homme avec lui-même. À force d'entamer le requiem pour l'autonomie de la volonté, on finirait par oublier que l'homme qui agit librement impose le respect de sa dignité d'être libre et que le recours à l'ordre public doit être sévèrement encadré » (D. Gutmann, « Les droits de l'homme sont-ils l'avenir du droit ? », in Mélanges F. Terré, Dalloz, PUF, Juris-Classeur, 1999, p. 329 et s., spéc. p. 336).

Document n° 6 : **Cass. com., 27 mai 2021**, n° 18-23.261, n° 18-23.699 (Extraits)

(…)
Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 mai 2018), la société Somado et la société Européenne de distribution (la société Eurodis), qui, ayant le même dirigeant et le même siège social, exercent la même activité de commercialisation de fournitures bureautiques et éducatives, se sont, en décembre 2000, engagées avec d'autres distributeurs de ces fournitures, dont la société Buropa, à respecter une charte, modifiée le 13 juillet 2004. Cette charte, réglementant différents aspects de leurs relations, contenait une clause, intitulée « Force commerciale » (la clause « Force commerciale »), par laquelle chacune d'entre elles s'engageait à n'embaucher, sauf accord explicite dérogatoire entre les parties concernées, aucun « commercial » employé par un autre membre du groupement ou ayant été employé par un autre membre du groupement et ayant quitté celui-ci depuis moins d'un an.

3. Faisant valoir que les sociétés Somado et Eurodis avaient, en violation de la charte, embauché un certain nombre de ses anciens commerciaux, lesquels avaient démarché ses clients au bénéfice de leur nouvel employeur, la société Buropa les a poursuivies en réparation.

Examen des moyens
(…)
Sur le premier moyen du pourvoi n° 18-23.261, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

9. Les sociétés Somado et Eurodis font grief à l'arrêt de dire qu'elles ont employé, au mépris de la clause « Force commerciale » de la charte 3B2S du 13 juillet 2004, Mme [B], Mme [N] et M. [E], entre le 7 septembre 2010 et le 7 septembre 2011, alors « qu'en toute hypothèse, apportant une restriction, tant à la liberté du commerce et de l'industrie qu'à la liberté du travail, la clause par laquelle une partie s'interdit d'embaucher, directement ou indirectement, les salariés ayant été employés par une autre partie, n'est licite que dans la mesure où elle est proportionnée à la protection des intérêts légitimes de son créancier ; que les sociétés Somado et Eurodis soutenaient que la clause selon laquelle chacune des cinq sociétés signataires, ainsi que l'ensemble des sociétés de distribution contrôlées par elles, membres du "groupement", s'engageait, sauf accord dérogatoire, à n'embaucher, directement ou indirectement, aucun commercial ayant été employé par un autre membre et ayant quitté celui-ci depuis moins d'un an, était disproportionnée, et donc nulle, en ce qu'elle interdisait l'embauche de commerciaux au sein de l'ensemble des sociétés membres du groupement, y compris dans un secteur d'activité économique pourtant différent de celui de leur ancien employeur ; qu'en se bornant à retenir, par un motif erroné, que cette clause ne porterait pas atteinte à la liberté du travail des commerciaux et, par des motifs inopérants, qu'elle ne constituait pas une clause de non-concurrence mais une clause de non-sollicitation, et que, interdirait-elle qu'un salarié ayant travaillé

pour l'un des membres dans le secteur des produits bureautiques soit embauché par un autre membre dans un autre secteur, "un accord dérogatoire" était néanmoins "possible dans cette hypothèse", sans constater qu'un tel accord aurait effectivement été conclu, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que cette clause était proportionnée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de la liberté du commerce et de l'industrie et le principe de la liberté du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ainsi que le principe de liberté du travail et le principe de liberté d'entreprendre :

10. Il résulte de la combinaison du premier alinéa de ce texte et des principes susvisés qu'une stipulation contractuelle qui porte atteinte aux dits principes n'est licite que si elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger compte tenu de l'objet du contrat.

11. Pour juger que la clause intitulée « Force commerciale » est valide, l'arrêt, après avoir relevé qu'elle est limitée dans le temps, retient qu'elle constitue une clause de non-sollicitation et non une clause de non-concurrence, dont elle n'est ni une variante ni une précision, et en déduit que le cadre rigoureux des clauses de non-concurrence ne trouve pas à s'appliquer. L'arrêt retient ensuite que cette clause, qui permet aux salariés de rechercher un emploi auprès d'autres entreprises non-membres du groupement, ne porte en conséquence pas atteinte à la liberté du travail et qu'elle n'est pas disproportionnée puisqu'elle précise que des accords dérogatoires sont possibles.

12. En se déterminant ainsi, alors que, conclue entre entreprises concurrentes, la clause litigieuse portait atteinte à la liberté du travail des personnes qui étaient contractuellement liées à ces entreprises ainsi qu'à la liberté d'entreprendre de ces dernières, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si ces atteintes étaient proportionnées aux intérêts légitimes que la clause était censée protéger, a privé sa décision de base légale.
(…)

PAR CES MOTIFS : …

CASSE ET ANNULE (…) l'arrêt rendu le 17 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

II.- Un contenu certain : la protection des intérêts individuels

Document n° 7 : **Cass. 1re civ. 16 avril 1996**, n° 93-19.661, Bull. civ. I, n° 184

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que depuis 1982 Mlle X... avait pour médecin traitant M. Z... ; qu'à la fin de 1988, elle a présenté à la cuisse droite un " sarcome des parties molles ", qui a nécessité plusieurs interventions chirurgicales, ainsi qu'un traitement de chimiothérapie ; que, par acte notarié du 13 mai 1989, Mlle X... a vendu à la SCI Le Clos des roses représenté par ses deux associés, les époux Z..., un immeuble situé à La Ciotat, moyennant le service d'une rente viagère annuelle de 144 000 francs ; que la venderesse s'est réservé un droit d'usage et d'habitation dans un appartement, que les débirentiers devaient aménager dans cet immeuble ; qu'hospitalisée du 17 au 26 mai 1989, puis partie le 20 juin 1989 dans une maison de retraite, B... Audry y est décédée le 6 juillet 1989, soit moins de deux mois après la signature du contrat de rente viagère ; que le 15 février 1990, M. A... et Mme Y..., agissant en leur qualité de légataires universels, ont assigné la SCI Le Clos des roses et les époux Cocucci en nullité de ce contrat ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juillet 1993) a accueilli leur demande ;

Attendu que la SCI Le Clos des roses et les époux Cocucci font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la nullité, pour défaut d'aléa, d'un contrat de rente viagère n'est encourue que dans la mesure où la maladie dont était atteint, au jour du contrat, le crédirentier, est directement à l'origine du décès prématuré de celui-ci ; que, dès lors, en relevant par motifs adoptés que le mal dont Mlle X... était atteinte, ne pouvait conduire qu'à une issue fatale à bref délai tout en retenant que la cause exacte de ce décès n'avait pas été déterminée, de telle sorte que le sarcome dont le médecin traitant avait connaissance n'était pas nécessairement à l'origine de la mort de la crédirentière, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé par fausse application les articles 1968 et 1975 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de leurs conclusions d'appel, les époux Z... avaient fait valoir que, dépourvu de lien avec l'affection cancéreuse, le décès de la crédirentière avait été probablement causé par un syndrome neurologique correspondant parfaitement à l'hémiplégie dont Mlle X... avait été victime brutalement quelques jours avant sa mort, et deux mois après la signature du contrat litigieux ; qu'il en résultait nécessairement que la vente du 13 mai 1989 n'était pas dépourvue d'aléa ; qu'en décidant le contraire, sans répondre à ce chef de conclusions, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 1975 du Code civil n'interdit pas de constater, pour des motifs tirés du droit commun des contrats, la nullité pour défaut d'aléa d'une vente consentie moyennant le versement d'une rente viagère, même lorsque le décès du crédirentier survient plus de vingt jours après la conclusion de cette vente ; qu'il n'est pas nécessaire, dans cette hypothèse, que le crédirentier soit décédé de la maladie dont il était atteint au jour de la signature du contrat ; qu'il suffit que le débirentier ait eu connaissance de la gravité de l'état de santé du vendeur ; qu'ayant relevé en l'espèce que M. Z..., débirentier, était depuis plus de six ans le médecin traitant de Mlle X..., crédirentière, qu'il n'ignorait rien de son état de santé tant en raison de la fréquence de leurs rapports que de ses

contacts avec les spécialistes appelés à la soigner, que sa patiente avait subi plusieurs interventions chirurgicales pour l'ablation d'une tumeur cancéreuse à la cuisse, et qu'elle suivait des séances de chimiothérapie au mois de mai 1989, c'est-à-dire à l'époque de la vente, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que le praticien, constatant l'état de déficience extrême de la malade dont il avait suivi l'évolution, avait été en mesure de prévoir l'imminence de son décès, de telle sorte que le contrat de rente viagère, dépourvu de tout aléa, se trouvait privé de cause et devait être annulé ; que, dès lors, les juges du second degré n'avaient pas à répondre aux conclusions inopérantes, selon lesquelles le décès de Mlle X... aurait été " probablement " causé par un syndrome neurologique, et non par le sarcome dont elle avait été victime fin 1988 ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

Document n° 8 : **Cass. 1re civ., 3 juillet 1996**, n° 94-14.800, Bull. civ. I, n° 286

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société DPM fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mars 1994) d'avoir annulé, pour défaut de cause, le contrat de création d'un « point club vidéo » et de location de cassettes conclu avec M. et Mme Y..., en retenant que la cause, mobile déterminant de l'engagement de ces derniers, était la diffusion certaine des cassettes auprès de leur clientèle et que cette exploitation était vouée à l'échec dans une agglomération de 1314 habitants, alors que, d'une part, dans un contrat synallagmatique la cause de l'obligation d'une partie réside dans l'obligation de l'autre partie, et qu'en l'espèce la cause de l'engagement des époux Y... était la mise à leur disposition des cassettes vidéo, et que, d'autre part, les motifs déterminants ne peuvent constituer la cause du contrat que dans le cas non relevé pas la cour d'appel où ces motifs sont entrés dans le champ contractuel ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, s'agissant de la location de cassettes vidéo pour l'exploitation d'un commerce, l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les parties était impossible, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat était dépourvu de cause, dès lors qu'était ainsi constaté le défaut de toute contrepartie réelle à l'obligation de payer le prix de location des cassettes, souscrite par M. et Mme Y... dans le cadre de la convention de création d'un « point club vidéo » ;

Que l'arrêt est ainsi légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Document n° 9 : **Cass. com., 9 juin 2009**, n° 08-11.420, *inédit*

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1131 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 17 avril 2002, la société Meria a conclu avec l'association Tourisme et culture Bordeaux, association des personnels des groupes La Poste et France Télécom (l'association), un contrat de location portant sur un lot de cassettes vidéo et DVD, pendant une durée de douze mois, selon un prix mensuel de 3 100 euros ; qu'après s'être acquitté du paiement d'une partie de ce prix, l'association a assigné la société Meria en annulation ou résolution de ce contrat, en remboursement de la somme versée, et en indemnisation de son préjudice ;

Attendu que, pour déclarer le contrat nul pour absence de cause, l'arrêt constate que l'objet de celui-ci, envisagé du point de vue de l'association, était de louer des cassettes et des DVD en vue de les diffuser à ses membres, au nombre d'environ 300, constitués de personnels de La Poste et de France Télécom ; qu'il relève que l'engagement résultant du contrat souscrit avec la société Meria, d'un montant de 37 200 euros, représentait plus du double de l'actif apparaissant sur les documents comptables au titre de l'exercice 2001, et que les pièces du dossier ne révèlent pas que l'association fût appelée à disposer au titre de l'année 2002 de ressources exceptionnelles ou susceptibles d'accroître notablement le budget de l'exercice précédent, de sorte qu'il est certain que le budget de l'association ne lui permettait pas de financer la location des vidéogrammes ; qu'il relève encore que l'importance de l'engagement financier mis à sa charge par le contrat l'empêchait de financer les autres objectifs poursuivis par celle-ci dans le domaine touristique et culturel ; qu'il relève enfin que, dans la mesure où les cassettes et DVD étaient destinés non seulement à être loués, mais aussi à être prêtés aux membres de l'association, le produit attendu des locations ne pouvait en aucun cas permettre d'assurer l'équilibre financier de l'opération ; qu'il en déduit que le contrat, en l'absence de contrepartie réelle pour l'association, ne pouvait être exécuté selon l'économie voulue par les parties ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cause de l'obligation d'une partie à un contrat synallagmatique réside dans l'obligation contractée par l'autre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel de l'association Tourisme et culture Bordeaux recevable, l'arrêt rendu le 29 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;